

통상임금의 개념 및 판단 기준

- 고정성 폐기를 통한 통상임금 법리의 변경

(Concept and Criteria of Ordinary Wages

- A Change in Legal Doctrine on Ordinary Wages through the
Abolition of Fixedness)

이 새 롬(Lee Sae-rom)

창원지방법원 통영지원 부장판사

www.kci.go.kr

요 지

대법원은 특정 시점에 재직 중인 근로자에게만 지급하는 임금(재직조건부 임금) 및 일정 근무일수를 충족하여야만 지급되는 임금(근무일수 조건부 임금)의 통상임금성이 문제 된 사건에서 ‘고정성’을 통상임금의 개념적 징표에서 제외하고 통상임금의 개념과 판단 기준을 재정립하는 전원합의체 판결을 선고하였다(대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결 및 대법원 2024. 12. 19. 선고 2023다302838 전원합의체 판결). 이는 ‘조건의 충족 여부와 관계없이 임금의 지급 여부나 지급액이 사전에 확정될 것’을 의미하는 고정성을 통상임금의 개념적 징표로 요구하여 재직조건부 임금 및 근무일수 조건부 임금은 고정성이 없다는 이유로 통상임금성을 부정한 종전 판례(대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결 등)를 변경한 것이다.

종전 판례가 제시한 고정성 개념은 법령에 근거가 없다. 고정성 개념은 당사자가 임금에 재직조건 등을 부가하여 그 임금을 통상임금에서 제외하도록 허용하여 통상임금 범위를 법령상 근거 없이 축소시키고 통상임금의 강행성을 잠탈하는 결과를 초래하였다. 이로써 연장·야간·휴일근로에 대해 법이 정한 정당한 보상이 이루어지지 못하여 연장근로 등을 억제하려는 근로기준법의 취지에 부합하지 않게 되었다. 이에 대법원은 기준임금으로서 요청되는 통상임금의 기능과 본질에 부합하는 방향으로 법령을 충실히 해석하여 고정성 개념을 폐기하고 통상임금의 본질인 소정근로 대가성을 중심으로 통상임금의 개념과 판단 기준을 새롭게 정립하였다. 대법원은 근로자가 소정근로를 온전하게 제공하면 그 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하도록 정해진 임금은 조건의 존부나 성취 가능성과 관계없이 통상임금에 해당한다는 새로운 법리를 판시하였다. 새로운 법리에 따르면, 소정근로를 온전하게 제공하는 근로자라면 충족할 재직조건이나 소정근로일수 이내의 근무일수 조건이 부가되어 있다는 사실만으로 그 임금의 통상임금성이 부정되지 않는다. 새로운 법리는 통상임금의 본질인 소정근로의 가치를 온전하게 반영하여야 한다는 요청과 기준임금으로서 요구되는 사전적 산정 가능성(통상임금 판단의 예측가능성)을 모두 충족하며 재직조건부 임금뿐 아니라 근무일수 조건부 임금 등 다양한 임금 유형에 정

합적으로 적용될 수 있는 지침을 제시하였다는 의의가 있다.

한편 대법원은 법적안정성과 신뢰보호를 위해 대상판결 선고일 이후 통상임금 산정부터 새로운 법리를 적용하되, 소송 계속 중인 당해사건 및 병행사건에는 새로운 법리를 소급 적용하도록 하였다(제한적 장래효). 이는 이번 판례변경이 갖는 막대한 파급효과와 종전 판례 법리에 대한 신뢰보호를 고려하여 판례변경의 취지를 미래지향적으로 살리면서도 당사자의 권리구제도 배려하기 위한 조치라고 할 수 있다.

주제어: 통상임금, 통상임금의 개념적 징표, 재직조건, 근무일수 조건, 고정성, 근로기준법 시행령 제6조 제1항, 판례변경의 소급효, 장래효

통상임금의 개념 및 판단 기준*

- 고정성 폐기를 통한 통상임금 법리의 변경

(대상판결: 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결,
대법원 2024. 12. 19. 선고 2023다302838 전원합의체 판결)

이 세 례

I. 사안의 개요

1. 대법원 2020다247190 사건

가. 사실관계

피고 소속 근로자로 재직 중이거나 퇴직한 원고(선정당사자), 선정자들, 원고(피상고인)는 특정 시점(지급일)에 재직 중인 근로자에게만 지급하는 조건(이하 ‘재직조건’이라 한다)이 부가된 정기상여금(일정한 대상기간에 제공되는 근로에 대응하여 1개월을 초과하는 일정 기간마다 지급되는 상여금을 말한다(대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결 참조))과 성과급 중 근무실적과 관계없이 일정하게 지급되는 최소 지급분이 통상임금에 포함된다고 주장하며 법정 통상임금을 기초로 재산정한 시간외근무수당 미지급분을 청구하였다.

나. 소송의 경과

제1심은 재직조건부 정기상여금은 고정성이 없다는 이유로 통상임금성을 부정하고, 성과급 최소 지급분은 통상임금에 해당한다고 보았다. 원심은 재직조건이 유효라고 보기 어렵고 정기상여금에 고정성이 인정된다는 이유로 재직조건부 정기상여금이 통상임금에 해당한다고 판단하고, 성과급 최소 지급분의 통상임금성도 인정하였다(원고들 일부 승소). 이에 대하여 피고는 원심판단은 재직조건부 임금의 고정성을 부정한 선례에 반한다는 등의 이유로 상고하였다.

* <https://doi.org/10.22825/juris.2025.1.72.015>

2. 대법원 2023다302838 사건

가. 사실관계

피고 소속 근로자인 원고들은 기준기간(상여금의 지급주기에 따라 2개월, 약 6개월, 약 1년이다) 내 15일 미만 근무한 경우 지급대상에서 제외하도록 규정된 정기상여금이 통상임금에 해당한다고 주장하며 이를 통상임금에 포함시켜 재산정한 연장근로수당 등 차액을 청구하였다.

나. 소송의 경과

원심은 일정 근무일수를 충족하여야만 지급하는 조건(이하 ‘근무일수 조건’이라 한다)이 부가된 정기상여금은 그 조건 성취 여부가 불확실하므로 고정성이 없다고 보아 통상임금성을 부정하였다(원고들 패소, 제1심 판단도 같다). 이에 대하여 원고들은 원심판단에 통상임금과 고정성에 관한 법리오해가 있다고 주장하며 상고하였다.

II. 통상임금에 관한 법령, 종전 판례 및 쟁점

1. 통상임금에 관한 법령 및 종전 대법원 판례

통상임금은 연장·야간·휴일근로(이하 ‘연장근로 등’이라 한다)에 대한 가산임금이나 해고예고수당을 산정하고 평균임금의 최저한을 구성하는 기준임금이다(근로기준법 제56조 제1항, 제26조, 제2조 제1항 제6호, 제2항). 특히 근로기준법 제56조 제1항에 따르면 연장근로 등에 관한 법정수당은 통상임금에 50% 이상 가산율을 곱하여 산정되므로 통상임금 범위는 임금 총액과 노사의 이해관계에 큰 영향을 미친다. 실제로 통상임금은 근로관계 소송에서 가장 빈번하게 문제 되어 온 쟁점 중 하나이다.

그런데 근로기준법은 통상임금을 다른 임금 산정을 위한 도구로 삼으면서도 통상임금의 개념과 판단 기준에 대해서는 규정하지 않았다. 근로기준법 시행령 제6조 제1항¹⁾의 통상임금 정의규정도 구체적 사안에서 통상임금성을 판단할 수 있는

1) 근로기준법 제6조(통상임금)

실천적 판단 기준으로 삼기에 부족한 부분이 있다. 이는 입법으로 통상임금의 범위를 명확하게 제시하는 미국이나 일본과 뚜렷하게 구별되는 점이다.

입법적 불명확성으로 인한 통상임금 범위 확정의 부담은 법원의 몫이 되었다. 대법원은 오랜 기간 판례를 축적하여 통상임금에 관한 해석론을 형성하여 왔다. 1990년대에 대법원은 통상임금을 ‘정기적, 일률적으로 소정근로의 양 또는 질에 대하여 지급하기로 된 임금으로 실제 근무일수나 실제 수령한 임금에 구애됨이 없이 고정적이고 평균적으로 지급되는 일반임금’이라고 정의하였고(대법원 1990. 11. 9. 선고 90다카6948 판결), ‘실제 근무일수나 수령액에 구애됨이 없이 정기적, 일률적으로 1임금산정기간에 지급하기로 정하여진 고정급 임금’이라고 정의하기도 하였으며(대법원 1992. 2. 14. 선고 91다17955 판결), ‘소정근로 또는 총근로의 대상으로 근로자에게 지급되는 금품으로서 그것이 정기적, 일률적으로 지급되는 것이면 원칙적으로 모두 구 근로기준법상의 통상임금이라 할 것이나, 근로기준법의 입법 취지와 통상임금의 기능 및 필요성에 비추어 볼 때 어떤 임금이 통상임금에 해당하려면 그것이 정기적, 일률적으로 지급되는 고정적인 임금에 속하여야 하므로 실제의 근무성적에 따라 지급 여부 및 지급액이 달라지는 임금은 고정적인 임금이라 할 수 없어 통상임금에 해당하지 아니한다.’고 판시하기도 하였다(대법원 1998. 4. 24. 선고 97다28421 판결). 그러던 중 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다91046 판결이 최초로 1개월을 초과하여 일정 기간마다 지급되는 정기상여금이 통상임금에 해당할 수 있음을 명시적으로 인정함에 따라, 어떠한 요건을 갖추어야 통상임금에 해당하는지에 대하여 대법원이 전원합의체 판결로 정확하게 판단해 주어야 한다는 사회적 요구가 커졌다.

이에 2013년에 대법원은 전원합의체 판결을 통하여 통상임금의 판단 기준과 개념적 징표의 의미를 구체적으로 제시하였다(대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결 및 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다94643 전원합의체 판결, 이하 통틀어 ‘2013년 전원합의체 판결’이라 한다). 2013년 전원합의체 판결은 어떠한 임금이 통상임금에 속하는지는 소정근로의 대가로 지급되는 금품으로서 정기적·일률적·고정적으로 지급된 것인지를 기준으로 객관적인 성질에 따라 판

① 법과 이 영에서 “통상임금”이란 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.

단하여야 한다고 판시하였다. 통상임금의 개념적 징표로 정기성, 일률성, 고정성을 요구하면서 그 각각의 의미를 아래와 같이 밝혔다.

정기성	일정한 간격을 두고 계속적으로 지급되어야 함
일률성	모든 근로자나 일정한 조건 또는 기준에 달한 모든 근로자에게 일률적으로 지급되어야 함
고정성	임의의 날에 소정근로를 제공하면 추가적인 조건의 충족 여부와 관계없이 당연히 지급될 것이 예정되어 임금의 지급 여부나 지급액이 사전에 확정되어 있어야 함

또한 2013년 전원합의체 판결은 다양한 임금 유형의 사례를 들어 고정성 판단에 관한 세부적인 기준도 제시하였는데, 재직조건부 임금 및 근무일수 조건부 임금에 대하여는 임의의 근로제공 시점에 조건의 성취 여부가 불확실하기 때문에 고정성이 부정된다고 판시하였다.

이는 통상임금 범위를 판례로 명확하게 하려는 시도였다. 하지만 그 후에도 고정성 개념을 둘러싼 논란은 계속되었다. 2013년 전원합의체 판결이 정립한 고정성 개념을 비판하거나 우회하여 통상임금성을 다른 각도에서 파악하려는 학문적, 실무적 시도가 이어졌다. 2010년대 후반부터는 하급심 실무에서도 재직조건, 근무일수 조건이 부가된 임금의 통상임금성에 관하여 엇갈리는 판단이 계속되는 등 혼란이 계속되었다.

2. 쟁점의 정리

이에 대법원은 재직조건부 정기상여금, 근무일수 조건부 정기상여금의 통상임금성이 문제 되는 사건들을 전원합의체에 회부하여 통상임금 법리에 관한 학계와 실무의 문제의식과 축적된 논의에 관하여 깊이 고민하였다. 전원합의체의 논의 대상이 된 쟁점은 ❶ 종전 판례가 제시한 고정성 개념을 통상임금의 개념적 징표로 계속 유지할 것인지, ❷ 그렇지 않다면 통상임금의 개념과 판단 기준을 어떻게 재정립할 것인지 여부이다.

Ⅲ. 대상판결이 실시한 통상임금에 관한 새로운 법리

1. 통상임금 개념의 재정립 방향

앞서 보았듯이 고정성 개념은 오랜 기간 판례의 해석론으로 이어져 오다가 11년 전 전원합의체 판결로 정립된 것이었다. 이러한 고정성 개념에 관한 판례를 변경하는 부담은 결코 적지 않았다. 2013년 전원합의체 판결이 통상임금 판단 기준을 세밀하게 집대성하고자 한 판결이고 그 법리가 그동안 노사 간 임금협상의 토대로 작용하여 왔음을 고려하면 판례변경 시 막대한 사회적 파급효과 예상되었다. 그러나 판례를 함부로 변경해서는 안 되지만 판례변경의 무게에 짓눌려 판례변경의 필요성과 당위성에 눈감아서도 안 된다. 대법원은 법 발전을 위하여 불가피하게 요구되는 판례변경을 논의하는 기회에 여러 임금 유형을 정합성 있게 처리할 수 있는 통상임금 개념을 제시함과 아울러 무엇보다도 아래에 밝히는 기준임금으로서 요구되는 통상임금 개념의 요청에 부합하는 방향으로 고정성 개념의 타당성을 근본적으로 재검토하였다.

첫째, 통상임금은 법적 개념이므로 법령상 정의에 충실하게 해석하여야 한다(법령 부합성). 둘째, 통상임금은 강행적 개념이므로 당사자가 법령상 통상임금의 범위를 임의로 변경할 수 없어야 한다(강행성). 셋째, 통상임금은 소정근로의 가치를 온전하게 담아낼 수 있는 개념이어야 한다(소정근로 가치 반영성). 넷째, 통상임금은 사전에 명확하게 산정될 수 있어야 한다(사전적 산정 가능성). 다섯째, 통상임금 개념은 연장근로 등의 억제라는 근로기준법의 정책 목표에 부합하여야 한다(정책 부합성).

대법원은 이러한 요청들을 종합적으로 고려할 때, 고정성은 통상임금의 개념적 징표라는 지위를 내려놓아야 한다는 대법관 전원의 일치된 결론에 이르렀다. 구체적인 이유를 분설하면 다음과 같다.

2. 고정성 개념이 폐기되어야 하는 이유

가. 법령 부합성

근로기준법 시행령 제6조 제1항은 통상임금을 “근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주

급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액”이라고 정의한다. 2013년 전원합의체 판결은 ‘임금의 지급 여부나 지급액이 사전에 확정될 것’을 ‘고정성’이란 개념적 징표로서 요구하였다. 그런데 이러한 의미의 고정성 개념은 위 시행령 조항을 비롯한 근로관계법령 어디에도 근거가 없다. 위 시행령 제6조가 ‘지급하기로 정한’이라는 문언을 포함하고 있기는 하다. 하지만 이 문언은 지급이 미리 정해진 상태, 즉 ‘소정성(所定性)’을 표현하고 있을 뿐이다. ‘소정성’은 모든 임금의 공통적 징표이다. 임금채권은 근로계약, 취업규칙, 또는 단체협약에서 임금을 ‘지급하기로 정한’ 때 비로소 발생하기 때문이다. 따라서 ‘소정성’은 통상임금에 특유한 개념적 징표가 아니다. 이를 위와 같은 의미의 ‘고정성’으로 변형하여 해석한 뒤 통상임금의 개념적 징표로서의 독자적 지위를 부여할 뚜렷한 문언상 근거도 없다. 그러한 해석이 입법자의 의사나 근로기준법의 목적에 부합하는 것도 아니다.

통상임금은 소정근로의 가치를 임금으로 전환한 개념이므로, 법령상 정의된 통상임금의 본질적인 판단 기준은 ‘소정근로 대가성’이다. ‘정기성’과 ‘일률성’은 이러한 ‘소정근로 대가성’ 있는 임금의 전형적 속성으로서, 임금의 지급 시기와 지급대상이 미리 일정하게 정해지도록 요구함으로써 통상임금의 범위를 사전에 합리적으로 결정하도록 하는 역할을 담당한다. 그런데 여기에 법령상 근거 없는 ‘고정성’이라는 개념적 징표를 더하는 것은 통상임금의 범위를 법령상 근거 없이 축소시킨다. 이를 우리 사회 상황과 노사 현실에 맞게 통상임금 범위를 합리적으로 제한하려는 정책적 의도가 갖는 대응으로 이해할 여지가 없지는 않다. 그러나 법원은 법령을 해석하는 기관이지 정책을 수립·조정하는 기관은 아니다. 논란의 여지가 있을수록 법령에 충실하게 해석하는 것이 바람직하다.

나. 강행성

통상임금은 연장근로 등에 관한 법정수당 산정의 기준이 되고, 연장근로 등에 대하여 법정의 합당한 보상을 하도록 한 강행법규와 관련되어 있다. 사회 전체적 관점에서 보면 통상임금은 가산율과 결합하여 연장근로 등을 억제하는 도구로 기능하기도 한다. 통상임금은 법정수당 미지급에 관한 형사처벌 규정(근로기준법 제109조 제1항, 제56조)의 구성요건에도 중대한 영향을 미친다. 따라서 통상임금은 당사자가 그 개념과 범위를 임의로 결정하거나 변경할 수 없는 강행적 개념이다

(2013년 전원합의체 판결 참조). 그러한 의미에서 통상임금은 ‘자율(Autonomy)’의 영역에 있지 아니하고 ‘후견(Paternalism)’의 영역에 있다.

이러한 통상임금 개념의 강행성은 계약자유 원칙이나 노사 간 협약자치 등 노사관계에 관한 자율의 요청과 양립할 수 있다. 사용자와 근로자는 임금 구조와 체계, 개별 임금 항목의 유형과 내용, 임금 총액 등을 자유롭게 정할 수 있고, 임금에 관한 조건도 자유롭게 부가할 수 있다. 그 조건은 강행규정에 위반되거나 탈법행위에 해당하는 등 별도의 무효 사유가 존재하지 않는 한 효력을 가진다. 그러나 조건의 효력 문제와 그 조건이 부가된 임금 항목의 통상임금성 문제는 구별하여야 한다. 전자는 자율의 영역에 속하고 후자는 후견의 영역에 속한다. 가령 어떤 임금 항목에 부가된 재직조건은 원칙적으로 유효하므로 그 기준 시점에 재직하지 않는 근로자에게는 해당 임금이 지급되지 않더라도,²⁾ 그 임금 항목이 다른 법정수당의 산정 기초를 이루는 통상임금인지는 이와 별도로 판단할 문제이다. 따라서 근로자가 퇴직하여 재직조건부 임금을 받지 못하더라도 퇴직 전 연장근로 등에 대해서는 재직조건부 임금을 포함한 통상임금에 기초하여 산정된 법정수당을 지급받는 것이 가능하다.

2013년 전원합의체 판결은 ‘근로관계 당사자가 어떤 임금 항목에 조건을 부가하여 그 지급 여부와 지급액이 사전에 확정될 수 없는 경우 고정성이 결여되어 통상임금이 아니다.’는 법리를 제시하였다. 이 판결의 근본적 문제는 자율의 영역에 속하는 ‘조건’을 후견의 영역에 속하는 ‘통상임금’과 부당하게 결부시켰다는 데 있다. 이로써 당사자가 어떤 임금에 재직조건이나 근무일수 조건과 같은 지급조건을 부가하여 쉽게 그 임금을 통상임금에서 제외할 수 있도록 허용함으로써 통상임금의 강행성을 잠탈할 위험이 초래되었다. 사용자의 우월적 지위에 기한 조건 부가를 통해 통상임금의 범위를 부당하게 축소할 위험도 초래하였다.

물론 조건의 유형과 내용에 따라서는 조건이 부가된 그 임금 항목의 통상임금성이 부정되는 경우도 있을 수 있다. 하지만 이는 해당 임금의 지급 여부와 지급액

2) 대상판결 선고 후 대법원은 좀 더 분명히 재직조건의 효력에 관하여 판시하였다. 즉, 노사가 어떤 임금의 내용을 형성하는 과정에서 그 임금을 지급받기 위하여 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 조건을 부가하는 것은 원칙적으로 그 임금이 지급되기 위한 기준 내지 임금의 지급대상을 정하는 것이 이미 지급하기로 정해져 있는 임금을 특정 시점에 재직하지 않는다는 이유로 포기하게 하거나 박탈하는 것이라고 보기 어려우므로, 특별한 사정이 없는 한 무효라고 볼 수 없다는 것이다(대법원 2025. 1. 23. 선고 2019다204876 판결 참조).

이 그 임금 항목에 부가된 조건에 좌우되기 때문이 아니라, 해당 임금의 객관적 성질에 따라 통상임금성을 실질적으로 판단하는 과정에서 그 조건의 존재가 소정근로 대가성 내지 정기성, 일률성을 부정하는 하나의 요소로 고려되었기 때문이다. 다시 말해 조건은 소정근로 대가성 등의 판단에 고려될 수는 있으나, 그 자체가 독자적인 고정성 부정 사유, 나아가 통상임금 부정 사유로서 작동할 수는 없다.

다. 소정근로 가치 반영성

통상임금의 본질은 근로자가 소정근로시간에 제공하기로 정한 근로의 가치를 평가한 기준임금이라는 데 있다. 따라서 통상임금 개념은 실근로와 무관하게 소정근로 그 자체의 가치를 온전하게 반영하여야 한다. 예컨대 근로자와 사용자가 '1주일에 40시간의 소정근로를 제공하면 그 대가로 100만 원을 지급하겠다.'고 미리 정하였다면 당사자가 40시간의 소정근로 가치를 반영하여 미리 정한 금액은 '100만 원'이다. 이 금액은 정기성과 일률성을 갖추는 한 통상임금으로 평가된다. 이처럼 미리 정해 놓은 통상임금에는 근로자가 1주일에 40시간의 근로를 온전하게 제공할 것이라는 가정이 당연히 깔려있다. 또한 그 가정은 논리적으로 근로자의 재직이라는 또 다른 가정도 당연히 품고 있다. 이러한 일련의 가정을 통상임금 산정의 당연한 전제로 삼아야 통상임금의 법률관계가 명확해진다.

예를 들어 월 200만 원인 기본급의 600%를 연 6회 분할하여 정기상여금으로 격월마다 200만 원씩 지급하는 회사에서 20년간 근무하다가 퇴직한 근로자가 있다고 가정하여 본다. 이 근로자는 20년 동안 총 120회에 걸쳐 격월마다 200만 원의 정기상여금을 지급받았으므로 이러한 정기상여금은 기본임금과 마찬가지로 근로자의 생계유지 근간이 되고 소정근로를 제공하는 것에 대한 기본적인 대가로서 근로자가 당연히 수령할 것을 기대하는 임금에 해당한다. 따라서 기본급(월 200만 원)에 정기상여금을 월 단위로 환산한 금액(100만 원)을 더한 월 300만 원이 근로자가 제공하는 소정근로 가치를 평가한 금액이라고 봄이 합당한데도, 근로관계의 종료 시점에 퇴직으로 인하여 마지막 정기상여금을 단 한 차례 수령하지 못한다는 사정만을 들어, 소정근로의 대가로서 지급되었음이 분명한 정기상여금을 통상임금에서 제외하는 것은 타당하지 않다.

통상임금은 가상의 도구개념이고 그 개념이 전제하는 근로자는 '소정근로를

온전하게 제공하는 근로자'이다. '소정근로의 온전한 제공'이라는 요건이 충족되기만 하면 바로 이를 이유로 제공되는 가상의 임금이 통상임금이다. 바꾸어 말하면 소정근로가 온전하게 제공되었다는 이유만으로 지급되는 것이 아닌 임금 항목(예컨대 순수한 의미의 성과급)은 통상임금이 아니다. 물론 '소정근로의 온전한 제공'이라는 가정이 현실에서 늘 성취되는 것은 아니다. 근로자가 개인 사정상 중도에 퇴직할 수도 있고 1주일에 30시간의 실근로만 제공하게 될 수도 있다. 비위행위로 징계를 받아 감봉될 수도 있다. 하지만 이 경우에도 통상임금은 근로자와 사용자가 미리 정한 '40시간의 소정근로 제공'이 온전하게 이루어지는 상황을 전제로 산정하여야 하고, 또 그렇게 하면 충분하다. 사후적으로 30시간의 실근로만 제공하였다는 사정은 통상임금이 아니라 실제 임금에 영향을 미칠 수 있을 뿐이다. 이처럼 통상임금을 실근로 또는 실제 임금과 분리하는 것은 법문에 부합할 뿐만 아니라 소정근로의 가치를 온전하게 반영하는 방식이다. 그렇게 해석함으로써 실제 임금의 변동 가능성이 통상임금에 투영되는 것을 막아 도구개념인 통상임금의 순수성과 명확성을 지켜낼 수 있다.

대법원도 일찍이 통상임금은 실제 근무일수나 실제 수령한 임금에 구애되지 않고 산정하여야 한다고 타당하게 판시하였다(대법원 1978. 10. 10. 선고 78다1372 판결, 대법원 1990. 11. 9. 선고 90다카6948 판결 등 참조). 그런데 2013년 전원합의체 판결은 고정성을 갖춘 임금을, 근로자가 임의의 날에 소정근로를 제공하면 '업적, 성과 기타 추가적인 조건의 충족 여부와 관계없이' 당연히 지급될 것이 예정된 임금이라고 정의하였다. 이는 바꾸어 말하면 조건 충족 여부에 임금 지급 여부가 연계되는 순간 고정성이 결여된다는 것이다. 만약 그 조건이 '실제 근무일수'처럼 소정근로가 아닌 실근로와 관련된 것이라면, 이러한 조건을 통로 삼아 실근로에 관한 요소가 통상임금 개념에 영향을 미치게 된다. 이는 소정근로 가치를 온전하게 반영해야 한다는 통상임금 개념의 요청을 위태롭게 한다.

라. 사전적 산정 가능성

통상임금이 연장근로수당과 같은 법정수당 산정을 위한 도구개념인 점을 고려하면 '사전적 산정 가능성'이 확보되어야 한다는 요청도 중요하게 고려하여야 한다. 그래야 사용자와 근로자는 연장근로 등에 대한 비용 또는 보상의 정도를 예측

하여 연장근로 등의 제공 여부에 관한 의사결정을 하고, 연장근로 등이 실제 제공된 때에 가산임금을 곧바로 산정할 수 있다. 종전 판례가 ‘조건의 성취 여부가 불확실하면 고정성이 결여되어 통상임금이 아니라는 법리’를 선언한 것도 외견상 명확하고 예측가능성 있는 기준을 제시하려는 방향성에서 비롯된 것일 수 있다. 그러나 이러한 고정성 개념은 앞서 보았듯이 법령 부합성, 강행성, 소정근로 가치 반영성 등과 같은 요건을 충족하지 못하여 통상임금의 개념적 징표로 삼을 수 없다.

기존 고정성 개념의 핵심을 이루는 ‘사전 확정성’은 애당초 완벽하게 달성할 수 없는 지표이기도 하다. 장차 무노동, 징계, 퇴직 등 사유가 발생하여 임금 지급이 좌절되는 상황이 발생할지는 그 누구도 미리 완벽하게 확정할 수 없다. 결국 통상임금의 사전적 산정 가능성은 사전에 확정될 수 없는 장래의 요소를 배제하고 ‘소정근로의 온전한 제공’이라는 전제적 개념에 충실함으로써 달성될 수 있다. 가령 1개월의 소정근로일수가 22일인데 그중 20일 이상 근무하면 지급하도록 정해진 임금의 경우, 실제 20일 이상 근무할 가능성은 통상임금에서 고려할 필요가 없다. 조건으로 부여된 근무일수가 소정근로일수 이내인 경우에는, 조건의 성취 가능성과 통상임금성을 결부시키지 않고 근로자가 소정근로일수를 모두 근무한다는 전제에서 통상임금 해당 여부를 판단하면 된다.

마. 정책 부합성

근로기준법의 목적은 ‘헌법에 따라 근로조건의 기준을 정함으로써 근로자의 기본적 생활을 보장, 향상’시키는 데 있다(근로기준법 제1조). 사용자는 근로계약을 체결할 때에 근로자에게 ‘소정근로시간’을 명시하여야 한다(근로기준법 제17조 제1항 제2호). 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없다(근로기준법 제50조 제1항). 연장근로 등은 근로자에게 더 큰 피로와 긴장을 주고 근로자가 누릴 수 있는 생활상의 자유시간을 제한한다. 이에 따라 근로기준법은 연장근로에 대해 제한 규정을 두면서(근로기준법 제53조), 연장근로 등에 대해 통상임금의 50% 이상을 가산한 임금을 지급하도록 정하고 있다(근로기준법 제56조). 이러한 연장근로 관련 규정 위반에 관한 처벌 조항도 두고 있다(근로기준법 제109조, 제110조 제1호). 이러한 일련의 규정들은 근로자의 인간다운 생활을 보장하기 위하여 가급적 연장근로 등을 억제하고 연장근로 등의 가치에 상응하는 금

전적 보상을 해 주려는 데에 그 취지가 있다(대법원 2023. 12. 7. 선고 2020도 15393 판결 등 참조).

그렇다면 연장근로 등과 불가분적으로 결합된 통상임금의 개념도 가급적 이러한 정책 목표와 부합하도록 이해되어야 한다. 그런데 고정성 개념은 통상임금의 범위를 법령상 근거 없이 축소시킨다. 이는 근로기준법의 정책 목표인 연장근로 등의 억제 이념에 부합하지 않는 결과를 야기한다.

3. 최근 판례의 흐름³⁾

앞서 언급하였듯이 이번 판례변경은 2013년 전원합의체 판결이 실시한 고정성 개념에 대한 하급심 실무와 학계의 문제의식을 토대로 이루어진 것이기도 하다.

2013년 전원합의체 판결이 선고된 이후 재직조건부 정기상여금의 통상임금성을 부정하는 데 대하여 학계에서 다양한 논의가 이어져 왔다.⁴⁾ 이러한 논의가 왕성한 가운데 하급심법원 실무는 단순히 임금에 어떤 조건이 부가되어 있는지에 따라 형식적, 기계적으로 통상임금성을 판단하는 것에서 탈피하여, 재직조건의 경우 문언에만 의존하는 것이 아니라 실질적인 제반 사정을 참작하여 재직기간에 비례하여 임금을 지급하는 이른바 ‘비례형 재직조건’이라고 해석하거나 기본임금의 성격을 갖는 정기상여금에 재직조건을 부가하는 것은 강행법규인 근로기준법의 규정 취지를 잠탈할 우려가 있다고 보는 등으로 소정근로 대가성에 주목하여 통상임금성을 인정하는 흐름을 형성하여 왔다.

이번 판례변경 전에 대법원은 하급심법원 실무의 문제의식을 수용하여 단체협

3) 이하 3.항 및 4.항은 대상판결에 판시된 부분은 아니나, 대상판결을 이해하는데 도움이 될 수 있다고 생각되어 기재하였다.

4) 이철수, “통상임금 관련 2013년 전원합의체 판결의 의미와 평가”, 노동법학 49호, 한국노동법학회(2014), 18 이하; 김성진, “통상성으로 본 대법원의 통상임금법리”, 노동법학 49호, 한국노동법학회(2014); 김성진, “통상임금의 판단에 있어서 임금지급기준의 효력”, 노동법학 51호, 한국노동법학회(2014); 김기선, “재직 중인 자에게만 지급되는 임금도 통상임금이다”, 노동판례리뷰(2014); 도재형, “통상임금 전원합의체 판결의 검토”, 노동법연구 36호, 서울대학교 노동법연구회(2014); 김홍영, “통상임금의 고정성 기준에 관한 재검토”, 노동법학 71호, 한국노동법학회(2019), 83~134; 김홍영, “통상임금에 포함시키지 않는 재직자 조건, 일정 근무일수 조건에 대한 비판적 검토”, 노동법연구 37호, 서울대학교 노동법연구회(2014), 42 이하; 최파라, “재직조건 또는 일정근무일수 조건이 있는 상여금의 통상임금성”, 법조 64권 7호, 법조협회(2015); 권오성, “정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 문제점”, 노동법논총 41집, 한국비교노동법학회(2017), 221~252; 권오성, “재직 조건 정기상여금의 통상임금성”, 중앙법학 20집 2호, 중앙법학회(2018), 321; 임상민, “재직조건부 정기상여금의 통상임금성”, 노동법연구 51호, 서울대학교 노동법연구회(2021) 등.

약 등에서 정기상여금을 특정 시점에 재직 중인 근로자에 한하여 지급한다는 규정을 둔 경우에도, 그 규정만을 근거로 이미 근로를 제공했다더라도 특정 시점에 재직하지 않는 사람에게는 정기상여금을 전혀 지급하지 않는 취지라고 단정할 것은 아니라고 판시하였다. 즉, 특정 시점 전에 퇴직하더라도 이미 근무한 기간에 비례하는 만큼 정기상여금을 지급해야 하는지는 단체협약 등에서 정기상여금을 근무기간에 비례하여 지급한다는 규정을 두고 있는지 여부뿐만 아니라, 정기상여금의 지급 실태나 관행, 노사의 인식, 정기상여금 그 밖의 임금 지급에 관한 규정 등을 종합하여 판단해야 하고, 비례적으로 지급되는 정기상여금이라면 통상임금에 해당한다는 것이다(대법원 2020. 4. 29. 선고 2018다303417 판결, 대법원 2022. 4. 28. 선고 2019다238053 판결 등 참조). 이는 제반 사정을 고려한 노사당사자의 객관적 의사해석을 통하여 비례형 재직조건이라고 보아 재직조건부 정기상여금의 통상임금성을 긍정한 것으로서 소정근로 대가성이 뚜렷한 정기상여금에 단순히 재직조건이 부가되어 있다는 사정만으로 통상임금에서 배제되는 결론의 문제점을 해결하려는 노력의 일환이었다고 평가할 수 있다.

또한 대법원은 2021년에 임금인상 소급분이 통상임금에 해당하는지 문제된 사건들에서 이미 고정성의 사전확정성을 대폭 완화하여 해석함으로써 통상임금성을 인정한 바 있다. 대법원 2021. 8. 19. 선고 2017다56226 판결 등을 비롯한 다수 판결은 매년 임금협상을 하며 인상된 기본급을 기준일로 소급하여 적용하기로 약정하고 이에 따라 매년 임금인상 소급분을 일괄 지급한 사안에서, 임금인상 소급분의 통상임금성을 인정하였다. 근로제공 후 나중에 단체협약을 체결할 때 비로소 소급적용 여부와 얼마를 소급하여 지급할지가 구체적으로 확정되기 때문에 종전 판례의 고정성(사전확정성) 법리를 엄격하게 적용하면 근로제공 당시에는 고정성이 없다고 볼 여지가 있어서 하급심 판단이 엇갈리고 있었다. 그런데도 대법원은 임금인상 소급분의 통상임금성을 인정하는 견해를 취하였다. 위 대법원 2017다56226 판결 등은 근로자들은 매년 반복된 합의에 따라 임금이 인상되면 소급기준일 이후의 임금인상 소급분이 지급되리라고 기대할 수 있었고, 소급적용 노사합의에 의해 소급기준일 이후 소정근로에 대한 대가가 인상된 기본급을 기준으로 확정된 이상 근로자들이 소정근로를 제공할 당시에는 임금의 인상 여부나 폭이 구체적으로 정해지지 않았더라도 통상임금이 아니라고 할 수 없다고 보았다. 이러한 최

근 관례의 흐름과 그 배후에 있는 문제의식에 비추어 보더라도 종전의 경직된 고정성 개념에 관한 재검토가 불가피한 면이 있었다.

4. 비교법적 검토

비교법적으로 살펴보면, 우리나라의 통상임금 제도는 미국의 통상임금률(Regular rate of pay) 제도 내지 일본 노동기준법상 할증임금(割増賃金)의 기준임금이 되는 '통상적인 근로시간 또는 근로일의 임금' 제도와 유사한 면이 있다. 그런데 미국과 일본은 근로의 대가로 지급되는 금품을 원칙적으로 통상임금으로 보되 법령에서 통상임금에서 제외되는 항목을 제한적으로 열거하는 방식을 취하고 있다. 미국 공정근로기준법(Fair Labor Standards Act, FLSA) 제207조 제e항은 '근로자에게 또는 근로자를 위하여 지급되는 모든 보수'가 통상임금에 포함된다고 간주하면서 선물, 근로시간에 대한 보상이 아닌 휴가, 휴일 등에 지급된 금품이나 실비 변상적 금품, 전적으로 사용자의 재량에 따라 임금의 지급 여부와 지급액이 결정되는 금품 등을 통상임금에서 제외되는 임금 항목으로 열거하고 있다. 일본의 경우 노동기준법 제37조 제1항, 제4항에서 초과근무에 대하여 통상의 근로시간 또는 근로일의 임금의 일정률을 할증임금으로 지급하도록 규정하고, 노동기준법 제37조 제5항 및 노동기준법 시행규칙 제21조에서 할증임금 산정 시 제외되는 임금 항목(가족수당, 통근수당, 별거수당, 자녀교육수당, 주택수당, 임시로 지급된 임금, 1개월을 넘는 기간마다 지급되는 임금)을 열거하고 있을 뿐, 지급의 사전확정성을 통상임금의 요소로 규정하고 있지 않다.

우리나라는 입법론적으로 미국, 일본과 같은 방식을 취하고 있지는 않으나, 어떠한 임금이 통상임금에 해당하는지를 판단하는 해석론을 정립할 때에 비교법적으로 우리와 유사한 제도적 환경에 있는 나라들이 단지 해당 임금이 제직조건이나 근무일수 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 그 임금을 통상임금에서 제외하지 않는다는 점을 참작할 필요가 있다.

5. 새로운 법리에 따른 통상임금 개념 및 판단 기준

위와 같은 고찰을 거쳐 대법원은 고정성을 통상임금의 개념적 징표로 볼 수 없다고 판단하였다. 고정성 개념의 폐기는 통상임금 범위의 확대로 이어지므로 단기

적으로 사용자에게 부담으로 작용할 수 있다. 그러나 이는 현행 법령하에서 마땅히 인정되었어야 할 통상임금 범위로의 정당한 회복이지 통상임금 범위의 부당한 확장이라고 보기는 어렵다. 이러한 부담은 나중에 살펴볼 판례변경의 소급효 제한으로 일정 부분 완화될 수 있다. 나아가 필요하다면, 새로운 통상임금 개념에 따른 노사의 자율적이고 점진적인 임금체계 조정, 통상임금의 개념, 가산율, 범위 등에 관한 입법의 명확화 내지 재정비, 근로시간 규제 체계에 관한 입법적 틀의 근본적인 변화 등 다른 방법을 통해 대처해야 할 문제이다.⁵⁾ 이는 노사 간 내지 사회적 합의의 영역으로 대법원이 관여할 문제는 아니나 고정성 개념의 폐기는 이러한 후속 논의의 계기가 될 수도 있다. 대법원이 새롭게 정립한 통상임금 개념과 판단 기준을 정리하면 다음과 같다.

가. 통상임금 개념 및 판단 기준

통상임금은 소정근로의 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하기로 정한 임금을 말한다. 근로자가 소정근로를 온전하게 제공하면 그 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하도록 정해진 임금은 그에 부가된 조건의 존부나 성취 가능성과 관계없이 통상임금에 해당한다.

나. 재직조건부 임금의 통상임금성

통상임금은 실근로와 구별되는 소정근로의 가치를 반영하는 도구개념이므로 계속적인 소정근로의 제공이 전제된 근로관계를 기초로 산정하여야 한다. 근로자가 재직하는 것은 소정근로를 제공하기 위한 당연한 전제이고, 퇴직은 실근로의 제공을 방해하는 장애사유일 뿐 소정근로의 대가와 개념상 아무런 관련이 없다. 따라서 어떠한 임금을 지급받기 위하여 특정 시점에 재직 중이어야 한다는 재직조건이 부가되어 있다는 사정만으로 그 임금의 소정근로 대가성이나 통상임금성이 부정되지 않는다.

5) 참고로 일본은 1개월 60시간까지 시간외근로 및 심야근로에 대해 25%, 60시간 초과 시간외근로에 대해 50%, 휴일근로에 대해 35% 이상 할증률을 부과하여 가산율을 유연하게 적용하고, 노사합의를 전제로 고도의 전문지식을 갖춘 연수(年收) 1,075만 엔 이상 근로자에게 근로시간 규제를 적용하지 않는다. 미국 공정근로기준법도 관리직, 행정직, 전문직, 컴퓨터 종사자, 상시 외근영업직 등에 대하여 초과근로수당(overtime pay) 등 면제(exemption) 조항을 두고 있다.

다. 근무일수 조건부 임금의 통상임금성

어떤 임금에 일정 근무일수를 충족하여야만 지급한다는 근무일수 조건이 부가되어 있더라도, 그와 같은 조건이 소정근로를 온전하게 제공하는 근로자라면 충족할 조건, 즉 소정근로일수 이내로 정해진 근무일수 조건인 경우에는 그러한 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 그 임금의 통상임금성이 부정되지 않는다. 설령 근로자의 실제 근무일수가 소정근로일수에 미치지 못하여 근로자가 근무일수 조건부 임금을 지급받지 못하더라도, 그 임금이 소정근로 대가성, 정기성, 일률성을 갖추고 있는 한 이를 통상임금에 산입하여 연장근로 등에 대한 법정수당을 산정하여야 한다. 통상임금은 실제 근무일수나 실제 수령한 임금에 관계없이 소정근로의 가치를 반영하여 정한 기준임금이기 때문이다. 반면 소정근로일수를 초과하는 근무일수 조건부 임금은 소정근로를 제공하였다고 하여 지급되는 것이 아니고 소정근로를 넘는 추가 근로의 대가이므로 통상임금이 아니다. 소정근로일수는 기본적으로 근로기준법이 정한 범위 내에서 당사자가 자유롭게 정할 수 있으나, 오로지 어떤 근무일수 조건부 임금을 통상임금에서 제외할 의도로 근무실태와 동떨어진 소정근로일수를 정하여 통상임금의 강행성을 잠탈하고자 하는 경우에는 그러한 합의의 효력이 부정될 수 있다.

라. 성과급의 통상임금성

근로자의 근무실적에 따라 지급되는 순수한 의미의 성과급은 일반적으로 소정근로의 대가성을 갖추었다고 볼 수 없으므로 판례변경 전과 마찬가지로 여전히 통상임금에 해당하지 않는다. 다만 근무실적과 무관하게 최소한도의 일정액을 지급하기로 정한 경우 그 금액은 소정근로의 대가에 해당한다.

IV. 판례변경의 소급효 제한

1. 소급효 제한의 필요성 및 고려할 요소

가. 판례변경의 소급효 제한의 필요성

판례변경을 통해 새로운 법리가 선언되더라도 새로운 법리는 애당초 정당한 법

의 내용으로서 과거 사실관계까지 규율하는 것이 원칙이다(판례변경의 소급효). 반면 판례를 변경하면서 변경된 판례를 장래의 사건에 대하여만 적용할 수 있다는 입장은 ‘판례변경의 장래효’라고 할 수 있다. 이때 선택적으로 내지 제한적으로 일부 사건에 대하여 새로운 법리를 소급 적용하되 그 외에는 장래효를 인정할 수도 있는데, 이를 ‘판례변경의 소급효 제한’ 내지 ‘제한적 장래효’(Selective prospectivity)라고 부를 수 있다.

이러한 판례변경의 소급효 제한 내지 제한적 장래효에 대하여 순수한 법 이론적 관점에서는 판례는 법이 아니라 구체적 사건에서 법을 사후적으로 확인하는 사법작용에 불과하므로 판례변경의 소급효 원칙이 예외 없이 관철되어야 하고, 장래효는 법을 해석하는 사법부의 역할을 넘는 것이어서 법 이론 및 헌법적 문제가 있으므로 사법상 거래안전 보호를 위한 법리(신의성실의 원칙, 착오, 보충적 해석, 권리남용 등)에 의하여 개별 사건에서 소급효를 제한하는 효과를 달성하는 접근이 더 타당하다는 견해가 있을 수 있다.⁶⁾ 그러나 대상판결은 판례변경의 소급효가 원칙임을 분명히 하면서도 극히 예외적으로 이 사건의 경우에는 법치주의로부터 파생된 신뢰보호 원칙에 기초하여 판례변경의 소급효를 제한하고 제한적 장래효를 인정하여야 한다는 결론을 내렸다. 그 이유를 설명하면 다음과 같다.

1) 판례법의 지위와 판례변경의 다양성

이론적 관점에서는 판례변경은 법의 변경이 아니므로 판례에 대한 신뢰보호는 그다지 문제 되지 않는다고 말할 수 있을지 모른다. 법원은 이미 법적으로는 존재하던 통상임금의 정당한 개념을 사후적으로 구체화하여 선언한 것일 뿐이므로 새로운 법리가 애당초 법의 정당한 입장으로서 적용되어야 한다는 논리이다. 그러나 국민이 실제로 몸담고 살아가는 법 현실의 세계가 반드시 그러한 것은 아니다. 현실의 삶의 현장에서 법을 구체화한 판례는 추상적인 법 못지않게 강력하고 현실적인 규범력을 발휘한다. 대부분 국민은 법과 판례를 애써 구별하지 않고 그 법질서의 원천을 구별할 필요성도 느끼지 못한다. 판례는 법이 아니라는 언명도 현실

6) 판례변경의 소급효와 장래효를 심층적으로 다룬 선행연구로, 김용담 편집대표, 주석민법(총칙(1))(4판), 한국사법행정학회(2010), 126~128(윤진수 집필 부분); 윤진수, “미국법상 판례의 소급효”, 저스티스 28권 1호(1995), 119; 윤진수, “상속회복청구권의 소멸시효에 관한 구관습의 위헌 여부 및 판례의 소급효”, 비교사법 11권 2호(2004), 197~198; 이동진, “판례변경의 소급효”, 민사판례연구 36권, 민사판례연구회(2014), 1134~1171.

에서는 다시 돌아 볼 필요가 있다. 법원은 판례를 통하여 법을 구체화하고 불가피한 경우 입법자에 준하여 법률의 내용을 보충하거나 심지어 이를 수정하기도 한다. 이러한 판례의 강력한 힘과 현실적 무게는 각종 법률에 규범적으로도 반영되어 있다(법원조직법 제7조 제1항 제3호, 소액사건심판법 제3조 제2호, 상고심절차에 관한 특별법 제4조 제1항 제3호, 제4호). 국민이 이러한 판례를 신뢰하여 이를 법률관계의 기초로 삼아 결정하고 행동하는 것은 자연스러운 일이다. 여기에서의 신뢰는 판례의 입장을 선호 또는 지지하는가의 문제가 아니다. 설령 판례에 비판적 태도를 가지더라도 그 판례를 법질서의 일부로 인정하여 자신의 법적인 의사결정과 행동의 기초로 삼았다면 판례에 대하여 신뢰를 부여한 것이다. 이러한 신뢰는 법원이라는 국가기관이 법에 관하여 공식적으로 표명한 입장에 대한 신뢰이므로 나중에 법원의 입장이 바뀌었다고 하여 그 이전의 입장에 대한 국민의 신뢰가 부당하다거나 보호 가치가 없다고 함부로 말할 수 없다. 여기에서 판례변경과 신뢰보호의 문제가 등장한다. 이는 판례가 법인가, 즉 판례의 법원성(法源性)과는 구별하여 논의될 수 있는 문제이다. 신뢰보호의 국면에서 중요한 것은 판례의 법원성 문제가 아니라 국민들이 판례를 신뢰하여 행동하였는가, 그 신뢰는 정당하고 합리적인 것으로 보호 가치가 있는가이다.

물론 판례를 변경할 때마다 종전 판례에 대한 신뢰가 보호되어야 하는 것은 아니다. 판례변경으로 인한 법적 불안정성은 우리 사법제도가 예정한 것이므로 원칙적으로 감수될 수밖에 없다. 하지만 이러한 원칙에도 예외가 있을 수 있다. 판례변경의 원인과 모습은 다양하다. 판례변경은 확인적 변경과 형성적 변경, 과거성 찰적 변경과 미래지향적 변경 등 다양한 양상으로 존재한다. 판례변경으로 침해될 수 있는 신뢰의 강도와 범위도 다양한 양상으로 존재한다. 이러한 다양한 양상을 고려하여 세밀한 형량 작업을 거친 결과 신뢰보호 필요성이 새로운 판례의 소급적 관철 필요성보다 압도적으로 강한 경우도 있을 수 있다. 이 경우에는 마치 법에 경과 규정을 두어 신뢰를 보호하듯이 헌법의 기본원리인 법치주의로부터 파생된 신뢰보호의 원칙(대법원 2006. 11. 16. 선고 2003두12899 전원합의체 판결 참조⁷⁾)에

7) 대법원 2006. 11. 16. 선고 2003두12899 전원합의체 판결: 우리 헌법이 기본원리로 삼고 있는 법치주의는 단순히 국민의 권리·의무에 관한 사항을 법률로써 정해야 한다는 형식적 법치주의에 그치는 것이 아니라, 그 법률의 목적과 내용이 기본권보장의 헌법이념에 부합되어야 한다는 실질적 법치주의를 지향하는 것이고, 이러한 실질적 법치주의의 실현을 위하여는 국가작용이 법률에 근거하여 행하여져야 한다는 것 못지않게 그 과정에 있어서 법적 안정성 또한 중요하게 고려되어야 한다. 이와 같은

기초하여 판례변경의 시적 범위를 장래로 제한할 수 있다. 이러한 장래효 인정이 사법권을 일탈한 처사라고 단정할 수도 없다. 때로는 법원은 불가피하게 법형성적 법해석을 하기도 한다. 법원이 법형성에 준하는 법해석을 하면서 그 해석의 시적 효력 범위를 장래로 설정함으로써 법해석의 적용 범위를 일부 제한하는 것이 허용되지 못할 이유가 없다. 오히려 이는 법원이 사법권을 행사함에 있어 신뢰보호라는 헌법적 요청을 존중하여 발휘하는 일종의 자제이다.

2) 선례의 태도

이러한 배경 아래 대법원도 판례변경이 종래 판례를 신뢰하여 형성된 수많은 법률관계의 효력을 일거에 좌우하게 되는 경우 “법적 안정성과 신의성실의 원칙에 기초한 당사자의 신뢰보호를 내용으로 하는 법치주의 원리”에 기초하여 판례변경의 장래효를 인정한 바 있다(대법원 2005. 7. 21. 선고 2002다1178 전원합의체 판결, 대법원 2008. 11. 20. 선고 2007다27670 전원합의체 판결, 대법원 2023. 5. 11. 선고 2018다248626 전원합의체 판결 등). 판례변경의 소급효를 제한한 선례들은 관습법 또는 사회질서가 판결 선고 시점을 기준으로 변경되었다고 선언하였다는 특수성을 지니고 있고 이러한 특수성이 판례변경의 장래효 인정을 좀 더 용이하게 하였던 측면은 있다.⁸⁾ 그러나 판례변경의 장래효가 오로지 이러한 사안의 특수성에서 비롯된 것만은 아니다. 위 선례들의 판결이유에 명시되었듯이 장래효 인정의 궁극적인 정당화 근거는 헌법상 법치국가 원리에 기초한 신뢰보호의 절실한 요청에 있다.

3) 개별적 신뢰보호 방식을 취하기 어려운 사정

학계에서 논의하듯이 일반적으로 판례변경에 관한 신뢰보호는 신의칙이나 착오 등 신뢰보호를 위한 개별적 법적 장치들에 의하여 이루어지는 것이 바람직하

실질적 법치주의의 원리는 형벌법규의 소급효 금지, 일사부재리 내지 이중처벌의 금지, 소급입법에 의한 재산권 박탈 금지 등을 규정하고 있는 헌법 제13조가 전형적으로 이를 구현하고 있는바, 이러한 명시적인 규정이 있는 경우뿐만 아니라 기존 법질서에 대하여 국민의 합리적이고 정당한 신뢰가 형성되어 있는 경우 이를 적절한 범위에서 보호하여야 한다는 이른바 신뢰보호의 원칙 역시 같은 이유에서 우리 헌법의 기본원리인 법치주의 원리에 속하는 것이라고 할 것이다.

- 8) 장래효 선례에 대하여 적어도 아직까지는 관습상 제도 내지 관습법이 이후 규범적 평가의 변화로 헌법 등 전체 법질서에 반하여 정당성과 합리성을 잃게 된 경우에 한하여 채택되었고, 문제 된 규범적 평가와 헌법 기타 법질서의 가치가 특히 양성평등에 관련되어 있었다고 분석한 논문으로 이동진(주 6), 1101.

다. 2013년 전원합의체 판결도 신의칙에 의거한 신뢰보호를 도모하였다.⁹⁾ 그러나 2013년 전원합의체 판결이 제시한 ‘중대한 경영상의 어려움’이나 ‘기업의 존립 위태’와 같은 요건이 신의칙과 어떻게 결부되는지는 이론적으로 분명하지 않았다. 또한 어느 정도가 되어야 위 요건을 충족하는지도 실무상 분명하지 않았다. 그 이후 대법원은 위 요건이 충족되었는지는 신중하고 엄격하게 판단하여야 한다고 함으로써 신의칙의 적용 범위를 좁혔다(대법원 2019. 2. 14. 선고 2015다217287 판결 등 참조). 그 결과 신의칙은 본래 의도했을 신뢰보호 기능을 충분히 수행하기 어려운 상황에 이르렀다.

한편 위와 같은 개별적 신뢰보호 방식은 사안별로 타당한 결론을 내리는 데에는 적합하나, 통상임금 사건처럼 광범위한 파급효를 가지므로 정형적인 해결 지침이 요구되는 사건유형에서 명확한 틀을 제시하는 데에는 한계가 있다. 신뢰보호에 관한 틀이 명확하지 않으면 결국 개별 사안별로 당사자들이 다투고 법원이 판단할 수밖에 없어 후속 분쟁이 늘어나고 혼란이 가중되는 한계가 있다. 제한적 장래효는 판례변경의 소급효와 장래효의 경계를 비교적 명확하게 제시함으로써 이러한 부작용을 막는다.

나. 판례변경의 소급효 제한 시 고려할 요소 및 대상사건의 경우

다만 판례변경의 장래효가 극히 예외적인 경우에만 인정되어야 한다는 점에는 이론의 여지가 없다. 대상판결은 어떤 사건이 이러한 극히 예외적인 경우에 해당 하는지는 종전 판례의 배경과 내용, 그 명확성과 구체성, 종전 판례에 대한 신뢰의 강도와 보호가치, 그러한 신뢰 아래 형성된 다른 법률관계의 내용과 중요성, 판례 변경의 영향을 받는 당사자들 및 이해관계의 범위와 규모, 판례변경으로 발생하는 파급효나 사회적 비용 등을 종합적으로 고려하면서 새로운 판례의 관철 필요성과 신뢰보호의 필요성을 세밀하게 형량하여 신중하고 엄격하게 판단하여야 한다고 실시하여 고려요소와 판단 기준을 밝혔다.

9) 정기상여금이 통상임금에 해당하지 아니한다고 오인하여 정기상여금을 통상임금에서 제외하기로 합의하고 이를 전제로 임금수준을 정한 경우, 근로자 측이 임금협상 당시 전혀 생각하지 못한 사유를 들어 정기상여금을 통상임금에 넣어 추가 법정수당을 구함으로써, 노사가 합의한 임금수준을 훨씬 초과하는 예상외의 이익을 추구하고 그로 말미암아 사용자에게 예측하지 못한 새로운 재정적 부담을 지워 중대한 경영상의 어려움을 초래하거나 기업의 존립을 위태롭게 한다면, 이와 같은 추가 법정수당 청구는 신의칙에 위배되어 받아들일 수 없다는 법리가 그것이다.

이어 대법원은 다음과 같은 사정들을 고려하면 이번 판례변경은 새로운 법리의 소급 적용을 제한하고 장래효를 인정할 필요가 있는 극히 예외적인 사건의 자격을 갖추었다고 판단하였다.

대법원은 1990년대 판례에서부터 고정성을 통상임금을 정의하는 요소로 삼아 왔고 2013년 전원합의체 판결은 고정성의 정의를 명확히 함으로써 통상임금에 관하여 구체적이고 분명한 지침을 제공하였다. 위 판결은 재직조건부 임금과 근무일수 조건부 임금은 고정성이 결여되어 통상임금이 아니라는 점도 분명히 하였다. 이러한 취지는 행정지도를 통해서도 현장에 관철되었다. 이 판결은 수많은 노사 현장에서 강행적 법질서로 받아들여져 노사 간 협상과 합의의 토대를 이루었다. 또한 연장근로 등에 관한 법정수당, 평균임금의 산정, 임금 총액의 결정 등 수많은 파생적 법률관계의 기초가 되었다. 이러한 영향을 받는 당사자들도 매우 많다.¹⁰⁾ 이들의 가족이나 이들을 고용한 사용자까지 고려하면 통상임금 범위 변경에 따른 영향을 받는 사람들의 수는 더 늘어난다. 통상임금의 추가 지급을 구하는 법적 분쟁이나 후속 소송도 벌어질 수 있다. 이로 인한 사회적 비용도 견잡을 수 없이 커질 수 있다. 사업장에 따라서는 임금협상 과정에서 종전 판례에 기초한 통상임금 범위를 토대로 다른 임금의 내용, 액수 등을 적절히 합의함에 따라 통상임금 분쟁 없이 장기간 안정적인 노사관계를 이어온 곳들도 있다. 이러한 과거 법률관계에 대해서까지 예외 없이 새로운 판례의 소급 적용을 관철하는 것이 반드시 실질적 정의 관념에 부합하는 결과가 된다고 단정하기 어렵다.

다. 소결론

판례변경의 장래효는 쉽사리 인정되어서는 안 된다. 그러나 대법원은 예외적인 사건에서 장래효를 이미 택한 바 있고, 중요한 것은 문제 된 사건이 장래효 인정 대상 사건인가이다. 적어도 통상임금 사건만큼 장래효의 필요성이 절실한 다른 사건을 떠올리기는 쉽지 않다. 이상에서 살펴본 이 사건의 특수성을 고려하면 통상임금에 관한 판례변경으로 인한 부담을 국민에게 전적으로 전가하거나 이를 도의시하는 것은 옳지 않다. 장래효로 인하여 사용자가 통상임금 범위 확장으로 인한

10) 2024. 8. 통계청의 관련 통계에 따르면 대한민국의 임금 근로자는 약 2,214만 3천 명에 이른다(통계청 홈페이지 2024. 8. 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 결과).

부담을 입는 대신 장래를 향해 그 부담을 감수하는 일부 혜택을 입게 된다고 하여 결론이 달라져야 하는 것도 아니다. 만약 법원이 통상임금 범위를 축소하는 판례 변경을 하였다면 근로자의 신뢰보호를 위한 정책도 마땅히 강구하였을 것이다. 신뢰보호는 중립적인 법 원칙이고 집단을 가려가며 선별적으로 적용되지 않는다.

2. 판례변경의 소급효 제한 범위(제한적 장래효의 인정 범위)

가. 이 사건의 경우 병행사건에도 소급효를 미치게 함이 타당함

기존 장래효 선례들에서 대법원은 전원합의체 대상인 당해사건에 한하여 판례 변경의 소급효를 인정하였다. 대법원은 재판의 대상이 된 당해사건에도 판례변경의 소급효가 인정되지 않는다면 이는 구체적인 사건에 있어서 당사자의 권리구제를 목적으로 하는 사법작용의 본질에 어긋날 뿐만 아니라 현저히 정의에 반하므로 당해사건에는 변경된 견해가 소급하여 적용되어야 한다고 밝힌 바 있다(대법원 2005. 7. 21. 선고 2002다1178 전원합의체 판결, 대법원 2008. 11. 20. 선고 2007다27670 전원합의체 판결, 대법원 2023. 5. 11. 선고 2018다248626 전원합의체 판결).

그런데 판례변경의 소급효가 언제나 당해사건에만 국한되어야 할 필연적인 이유는 없다. 사건의 고유한 특성을 바탕으로 신뢰보호의 필요성과 평등원칙의 요청 등을 고려한 세밀한 형량을 통해 소급효의 범위를 정할 수 있다. 대상판결은 이 판결 선고일 이후의 통상임금 산정부터 새로운 법리를 적용하되, 당해사건뿐 아니라 병행사건(이 판결 선고 시점에 동일한 쟁점으로 통상임금 해당 여부가 다투어져 법원에 계속 중인 사건)에도 판례변경의 소급효가 인정되어야 한다고 판시하였다. 이러한 결론은 다음과 같은 논거에서 정당화될 수 있다.

1) 재직조건 및 근무일수 조건부 임금의 통상임금성이 쟁점인 다수 사건들이 법원에 계속 중이라는 점에서 이 사건은 당해사건에만 판례변경의 소급효를 인정한 대법원 선례 사안들과 같지 않다. 여성에게도 중증원의 자격을 인정할 것인가(대법원 2005. 7. 21. 선고 2002다1178 전원합의체 판결 및 대법원 2005. 7. 21. 선고 2002다13850 전원합의체 판결) 또는 제사주재자를 어떤 방식으로 결정할 것인가(대법원 2008. 11. 20. 선고 2007다27670 전원합의체 판결 및 대법원 2023. 5. 11. 선고 2018다248626 전원합의체 판결)에 관한 병행사건은 거의 없었거나 이 사

건 병행사건들보다 그 수가 현저하게 적었을 것으로 보인다. 하지만 이 사건에서는 병행사건이 많아 그 처리 문제를 숙고할 필요성이 더욱 크다. 이 사건 병행사건에는 상고심에 계속 중인 사건들도 여럿 있다. 그런데 우연히 어떤 사건이 판례변경 대상 사건이 되었다는 사정 때문에 그 사건의 당사자만 권리구제를 받고 나머지 사건의 당사자들은 권리구제를 받지 못하는 것은 수긍하기 어려운 결론이다. 병행사건 당사자들도 판례변경에 함께 기여한 주체이고 판례변경의 여정에 무임승차하지 않았다. 이들을 당해사건 당사자와 차별하여 취급할 합리적 이유를 찾기 어렵다.

2) 한편 소를 제기하지 않은 집단에 판례변경의 소급효를 인정하지 않는 것이 부당하게 가혹한 결과라고 하기도 어렵다. 이들은 판례변경 시점까지 기존 판례에 대해 소 제기라는 형태로 적극적인 문제제기를 하지 않은 채 기존 판례 법리에 따라 자신의 법률관계를 형성하였다. 그 법률관계를 그대로 승인한다고 하여 이들이 예상하지 못한 불이익을 입게 되는 것이 아니다. 또한 이들은 소를 제기한 집단의 덕분에 비용이나 노력을 투입하여 소를 제기하지 않고도 장래를 향하여 새로운 법리를 적용받게 되었다. 이러한 일련의 상황을 종합적으로 고려하면, 이들에게 법적으로 감내하기 어려운 불이익이나 불합리한 차별대우가 발생하였다고 보기 어렵다.

3) 대상판결에 직접적으로 언급되지는 않았지만, ‘위헌결정의 소급효’에 관한 선례도 참고할 수 있다. 헌법재판소법 제47조 제2항은 위헌결정의 장래효를 규정한다. 그런데 이러한 장래효 원칙에도 불구하고 대법원은 그동안 위헌제청을 한 ‘당해사건’, 위헌결정 전에 그 법률 또는 법률 조항의 위헌 여부에 관하여 헌법재판소에 위헌제청을 하였거나 법원에 위헌제청신청을 한 ‘동종사건’, 따로 위헌제청신청은 하지 않았지만 그 법률 또는 법률 조항이 재판의 전제가 되어 법원에 계속 중인 ‘병행사건’에 대하여 소급효를 인정하여야 한다고 판시하여 왔다(대법원 1991. 12. 24. 선고 90다8176 판결, 대법원 2017. 3. 9. 선고 2015다233982 판결 등 참조. 또한 헌법재판소 1993. 5. 13. 선고 92헌가10 등 전원재판부 결정도 참조). 이는 대법원이 법적 안정성과 개인의 권리구제 필요성 등 여러 가치를 비교 형량하여 위헌결정 효력의 시적 범위에 관하여 판단한 것이다. 법원이 판례의 형태로 법의 내용을 형성적으로 구체화하였는데 그 판례가 타당성을 가지지 않아 변경하는 상황

은 법률이 위헌이라는 이유로 위헌결정의 형태로 변경되는 상황과 유사한 면이 있다. 어느 경우이든 법질서의 내용을 변경하면서 그 변경으로 새롭게 존재하게 되는 법 또는 법리를 어느 범위에서 소급시킬 것인가, 또한 그것이 평등원칙과의 관계에서 어떻게 정당화될 수 있는가에 관한 공통의 문제를 다루고 있기 때문이다. ‘당해사건’을 넘어서 ‘동종사건’과 ‘병행사건’에도 위헌결정의 소급효를 인정한 선례의 태도는 이 사건 판례변경의 소급효 인정 범위 결정에도 참고가 된다.

나. 병행사건의 의미와 범위

구체적으로 어떠한 사건들이 병행사건(‘이 판결 선고 시점에 이 판결이 변경하는 법리가 재판의 전제가 되어 통상임금 해당 여부가 다투어져 법원에 계속 중인 사건들’)에 해당하여 새로운 법리가 소급 적용되는 것인지 문제 될 수 있으므로 이에 관하여 살펴본다.

1) 소송계속의 의미

판례는 중복제소금지(민사소송법 제259조)에서 소송계속 시점을 소장 부분 송달 시로 보므로,¹¹⁾ 여기서 소송계속도 같은 의미로 새길 수 있다. 즉, 대상판결 선고 시점인 2024. 12. 19. 현재 소장 부분이 피고에게 송달되어야 ‘소송계속’이 있다고 볼 수 있다. 이런 경우가 세세하게 문제 될 여지는 드물겠지만 문제 되면 위와 같이 해석하면 될 것으로 보인다.

2) “통상임금 해당 여부가 다투어져”의 의미

대상판결이 선고되기 전까지는 종전의 고정성 판례 법리가 유지되고 있었기 때문에 하급심에서는 ‘조건의 효력’이 인정되지 않는다고 다투면서 조건부 임금이 통상임금에 해당하지 않는다고 주장하는 사건들이 상당수 있었다. 조건의 효력을 다툰 사건도 결국 조건부 임금의 통상임금성이 쟁점으로 다투어진 사건으로 볼 수

11) 대법원 2018. 7. 12. 선고 2018다217820 판결: 채권자대위소송이 법원에 계속 중일 때 다른 채권자가 같은 채무자를 대위하여 같은 제3채무자를 피고로 하여 소송을 제기한 경우 두 소송의 소송물이 같을 때에는 그 가운데 나중에 계속하게 된 소송은 중복제소금지의 원칙을 위배하여 제기된 부적법한 소송이어서 각하를 면할 수 없고, 이 경우 전소, 후소의 판별기준은 소송계속의 발생 시기, 즉 소장이 피고에게 송달된 때의 선후에 의한다(대법원 1989. 4. 11. 선고 87다카3155 판결 등 참조).

있으므로, 대상판결 선고 시 소송계속 중인 위와 같은 사건들도 병행사건에 포함되고 새로운 법리가 적용된다고 보아야 한다.

3) 청구의 시적, 물적 확장의 경우 병행사건 해당 여부

한편 대상판결 선고 전에 이미 소를 제기한 근로자들이 대상판결 선고 이후 ‘이미 제소한 기간 이후의 후속 기간에 대한 청구’를 추가하거나(시적 확장) 기존에 주장한 임금 항목 외에 ‘다른 임금 항목이 통상임금에 포함됨을 주장하는 청구’를 추가하여(물적 확장) 대상판결 선고일 전의 추가 법정수당을 구하는 경우가 있을 수 있다. 이때 병행사건 당사자들이 대상판결 선고 이후 ‘별소’를 제기한 경우는 병행사건의 정의인 “이 판결 선고 시점에 통상임금 해당 여부가 다투어져 법원에 계속 중인 사건들”에 해당하지 않음이 명확하므로, 새로운 법리가 별소에 적용될 수 없다. 또한 소송법상 청구기초의 동일성이 인정되지 아니하여 청구의 추가가 허용되지 않거나 소멸시효가 완성된 경우에도 당연히 그러한 확장된 청구가 받아들여질 수 없을 것이다. 다만 이러한 후속 기간 내지 다른 통상임금 항목에 관한 청구가 대상판결 선고 당시 계속 중이던 사건에서 적법한 청구 확장의 형태로 이루어진 경우에는, 위와 같은 청구 부분을 대상판결 선고 시점에 계속 중인 병행사건의 범위에 포함된다고 보아 새로운 법리를 소급하여 적용할 것인지가 문제 될 여지가 있다. 대상판결은 이러한 문제에 대해서까지는 구체적으로 실시하지 않았다. 대상판결의 선고일 현재 현실적으로 권리를 구제받기 위하여 통상임금 해당 여부가 다투어져 법원에 계속 중인 부분에 한하여 병행사건으로 볼 것인지, 시적·물적 확장 부분도 병행사건에 포함시켜 확장된 부분까지 새로운 법리를 일관되게 적용할 것인지는 후속 판결을 통하여 보다 분명히 정리될 수 있을 것이다.

V. 대상판결의 결론, 영향, 의의

1. 대상판결의 결론

대법원은 새로운 법리에 따라 재직조건이 부가된 정기상여금과 소정근로일수에 미치지 않는 근무일수 조건이 부가된 정기상여금의 통상임금성을 인정하였다. 각 사건에서의 구체적 판단을 표로 정리하면 다음과 같다.

사건	판단 이유	결론
대법원 2020다 247190 사건	① 이 사건에서 문제 된 정기상여금은 기준급여의 850%를 연간 일정한 주기로 분할하여 지급하는 임금임 ⇨ 재직조건에도 불구하고 통상임금에 해당함 ② 성과급 중 최소 지급분도 소정근로 대가로서 설령 재직조건이 있더라도 통상임금에 해당함 ③ 원심이 고정성을 통상임금의 개념적 징표로 보아 이를 전제로 판단한 부분은 잘못이나 이 사건 상여금이 통상임금이라고 인정한 원심의 결론은 정당함	상고 기각
대법원 2023다 302838 사건	① 이 사건에서 문제 된 정기상여금은 통상임금의 750%를 연간 일정한 주기로 분할하여 지급하는 임금임 ② 상여금을 지급받기 위해 요구되는 근무일수 15일은 상여금의 기준기간(최소 2개월~최대 1년)에 해당하는 소정근로일수에 미치지 않으므로, 소정근로를 온전하게 충족하는 근로자라면 충족할 근무일수임 ③ 근무일수 조건에도 불구하고 정기상여금은 통상임금에 해당함	파기 환송

2. 대상판결이 미칠 영향(후속사건의 처리)

가. 소정근로 대가성, 정기성, 일률성의 판단 문제

판례변경 전에는 ‘고정성’에 따라 통상임금성이 좌우되는 경우가 많았다. 즉, 통상임금의 본질은 소정근로 대가성에 있는데도, 어떤 임금 항목이 소정근로의 대가인지보다 그 임금에 재직조건이나 근무일수 조건이 부가되어 있는지만을 형식적으로 따져 통상임금 해당 여부를 판단하는 경우가 많았다. 그러나 고정성 개념이 폐기됨에 따라 종전에 재직조건 내지 근무일수 조건의 부가로 인하여 고정성이 결여되어 통상임금이 아니라고 판단하여 온 임금 항목에 대하여 이제 소정근로의 대가성, 정기성, 일률성이 인정되는지 여부에 관한 정면 판단이 필요하게 되었다.

대법원 1995. 12. 21. 선고 94다26721 전원합의체 판결로 임금을 근로의 대가와 생활보장적 임금으로 구별하는 이른바 임금2분설이 폐기된 이상 대부분 임금 항목은 근로계약 등에서 제공하기로 정한 소정근로의 대가로서 지급되는 것이라고 볼 여지가 높을 것으로 보이기는 한다. 다만 그동안 재직조건 등이 부가되어 있어 통상임금에서 제외되어 왔던 조건부 복리후생적 금원의 경우¹²⁾ 경계적 사안에

12) 가령 조건부 생일지원금, 창립기념일 지원금, 개인연금지원금, 단체보험료지원금, 경조사비, 선물비, 휴가비 등이 문제 될 여지가 있다.

서 소정근로의 대가가 아닌 복리후생적 성격의 금원에 불과한지, 애초에 임금인지 아닌지, 정기성과 일률성이 인정되는지 등이 다투어질 여지가 있을 수 있다고 보인다. 종전에 ‘고정성’이라는 명확한 징표는 ‘조건의 부가 여부 및 성취가능성’을 기준으로 통상임금성 당락을 쉽게 확정지을 수 있게 하였지만, 이러한 고정성 개념은 법령 부합성, 강행성, 소정근로 가치 반영성, 정책 부합성과 같은 통상임금의 정당한 요청을 충족하지 못하여 유지할 수 없게 되었다. 앞으로는 ‘소정근로의 대가’라는 통상임금의 본질적 속성과 이를 뒷받침하는 ‘정기성’, ‘일률성’이라는 개념적 징표를 통하여 개별 사안에서 통상임금 해당 여부에 관한 합리적인 결론을 도출하여야 할 것이다.

또한 대상판결은 고정성이 폐기되어도 통상임금을 이루는 개념에는 ‘임금 지급에 관한 일정한 사전적 규율’의 의미가 내포되어 있으므로, 소정근로의 제공과 관계없이 일시적이거나 변동적으로 지급되는 금품은 여전히 통상임금에서 제외된다는 점을 지적하였다. 고정성을 폐기하였다고 하여 일시적, 변동적 금품이 모두 통상임금의 범위에 포함되는 것은 아님을 유의할 필요가 있다.

나. 성과급의 통상임금 해당 범위

대상판결은 순수한 의미의 성과급, 즉 근로자의 근무실적에 따라 지급되는 성과급에 대하여는 일반적으로 소정근로 대가성을 부정하고, 다만 근무실적과 무관하게 최소한도의 일정액을 지급하기로 정한 경우 그 금액에 대하여는 소정근로 대가성을 인정하였다. 종전 판례는 성과급 중에서도 근무실적과 무관하게 최하 등급을 받더라도 최소한도의 지급이 확정되어 있는 부분은 ‘고정적 임금’이라고 보아 통상임금에 해당한다고 보면서, 고정성 개념에 따라 그 성과급이 어느 연도에 대한 임금인지를 확정하고 해당 연도에 임금의 지급 여부나 지급액이 확정되어 있는지를 기준으로 통상임금 해당 여부를 가려 왔다. 이러한 법리에 따라 전년도 근무실적에 따른 성과급을 전년도 출근일수에 비례하여 지급하면서 당해 연도 신규입사자 또는 전년도에 휴직 등으로 근로하지 않았던 근로자의 경우 당해 연도에 근로하더라도 성과급을 지급하지 않고, 전년도 퇴사자의 경우 당해 연도에 근로를 제공하지 않더라도 성과급을 지급한 경우와 같이 그 성과급이 ‘전년도 근로’에 대한 대가임을 추단할 수 있는 사정이 있는 경우에는 ‘전년도 임금’인데도 지급 시기

만 당해 연도로 미루었을 뿐이라고 보아 전년도에 근무실적 평가가 완료되어 지급 여부나 지급액이 확정되지 못한 이상 전년도에 대한 임금으로서의 고정성을 인정할 수 없다고 본 판결들이 있었다(대법원 2020. 6. 11. 선고 2017다206670 판결 등 참조). 그러나 이제 고정성 개념이 폐기됨에 따라 종전의 고정성(사전확정성) 개념을 기준으로 최소 지급분의 통상임금 해당 여부를 가릴 수 없게 되었다. 성과급의 통상임금성에 관하여는 후속 사건에서 보다 분명한 판단 기준이 제시될 수 있을 것으로 예상된다.

3. 대상판결의 의의

대상판결은 통상임금의 본질에 관하여 근본적인 통찰을 거친 결과, 통상임금이 소정근로 가치를 반영한 기준임금으로서 갖추어야 할 정당한 개념의 요청을 5가지로 정리하였다. 그러한 요청에 비추어 통상임금 개념을 재정립하면 종전 판례의 고정성 개념은 유지될 수 없다고 선언하였다. 대상판결은 통상임금의 기능과 본질에 부합하는 방향으로 법령을 충실히 해석하여 고정성을 폐기하고 통상임금의 본질인 소정근로 대가성을 중심으로 통상임금 개념을 새롭게 정립하였다는 큰 의의가 있다. 대상판결이 실시한 통상임금에 관한 새로운 법리는 통상임금의 본질인 소정근로의 가치를 온전하게 반영하여야 한다는 요청과 기준임금 내지 도구개념으로서 요구되는 사전적 산정가능성(통상임금 판단의 예측가능성)을 모두 충족하며, 재직조건부 임금뿐 아니라 근무일수 조건부 임금 등 다양한 임금 유형에 정합적으로 적용될 수 있는 지침이 될 것으로 기대된다.

한편 대상판결은 새로운 법리에 대하여 제한적 장래효를 인정하였다. 이는 종래 판례에 대한 신뢰를 보호하되 그 범위를 합리적으로 제한하는 것으로 판례변경의 취지를 미래지향적으로 살리면서 당사자의 권리구제도 배려하여 판례변경으로 인하여 발생하는 문제를 최소화하기 위한 불가피한 대책이다. 대상판결은 막대한 파급효와 신뢰보호의 필요성을 고려하여 장래효를 채택하되 동종 쟁점 사건이 다수 있는 특수성과 평등원칙의 요청 등을 고려해 장래효를 취한 판결 중에서는 최초로 병행사건까지 소급효를 미치도록 하였다. 대상판결은 장래효를 취할 수밖에 없는 필요성과 논거, 고려요소와 기준을 비교적 상세히 제시하였다는 점에서도 의의가 있다.

노사 간 이해관계가 첨예하게 대립하고 사회적으로 중차대한 영향을 미칠 수 있는 문제이니 만큼 대법원은 통상임금이란 무엇인가에 대한 근본적 물음에 대하여 숙고와 합의를 거친 끝에 대법관 전원의 일치된 의견으로 판례변경에 이르렀다. 갈등의 양상이 복잡해지고 이해관계 대립이 격화됨에 따라 사회문제의 해결이 어려워지는 상황에서, 토론과 설득을 통해 통합적인 결론을 도출하고 판례변경에 따라 문제 되는 신뢰보호에 대하여도 세밀한 방안을 제시한 대상판결이 주는 메시지와 의미가 크다고 생각된다.

<참고문헌>

김용담 편집대표, 주석민법[총칙(1)](4판), 한국사법행정학회(2010).

권오성, “재직 조건 정기상여금의 통상임금성”, 중앙법학 20집 2호, 중앙법학회(2018).

_____, “정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 문제점”, 노동법논총 41집, 한국비교노동법학회(2017).

김기선, “재직 중인 자에게만 지급되는 임금도 통상임금이다”, 노동판례리뷰(2014).

김성진, “통상성으로 본 대법원의 통상임금법리”, 노동법학 49호, 한국노동법학회(2014).

_____, “통상임금의 판단에 있어서 임금지급기준의 효력”, 노동법학 51호, 한국노동법학회(2014).

김홍영, “통상임금의 고정성 기준에 관한 재검토”, 노동법학 71호, 한국노동법학회(2019).

_____, “통상임금에 포함시키지 않는 재직자 조건, 일정 근무일수 조건에 대한 비판적 검토”, 노동법연구 37호, 서울대학교 노동법연구회(2014).

도재형, “통상임금 전원합의체 판결의 검토”, 노동법연구 36호, 서울대학교 노동법연구회(2014).

윤진수, “미국법상 판례의 소급효”, 저스티스 28권 1호(1995).

_____, “상속회복청구권의 소멸시효에 관한 구관습의 위헌 여부 및 판례의 소급효”, 비교사법 11권 2호(2004).

이동진, “판례변경의 소급효”, 민사판례연구 36권, 민사판례연구회(2014).

이철수, “통상임금 관련 2013년 전원합의체 판결의 의미와 평가”, 노동법학 49호, 한국노동법학회(2014).

임상민, “재직조건부 정기상여금의 통상임금성”, 노동법연구 51호, 서울대학교 노동법연구회(2021).

최파라, “재직조건 또는 일정근무일수 조건이 있는 상여금의 통상임금성”, 법조 64권 7호, 법조협회(2015).

〈Abstract〉

Concept and Criteria of Ordinary Wages

– A Change in Legal Doctrine on Ordinary Wages through the
Abolition of Fixedness

(Subject case: Supreme Court en banc Decisions 2020Da247190
Decided December 19, 2024 and Supreme Court
en banc Decisions 2023Da302838 Decided December
19, 2024)

Lee Sae-rom

The Supreme Court rendered a judgment redefining the concept and criteria of ordinary wages by excluding “fixedness” from conceptual criteria of ordinary wages through Supreme Court en banc Decisions 2024Da247190 and 2023Da302838 decided December 19, 2024, whose main issue lies in whether wages paid only to employees who were on duty at a specific point in time (wages conditional on continued employment) and wages paid only if a certain number of working days were met (wages conditional on days worked) may be deemed ordinary wages. As this judgment requires “fixedness”, meaning that “the payment and amount of wages should be determined in advance regardless of whether certain conditions are met”, as a conceptual criterion of ordinary wages, the previous precedents, including Supreme Court en banc Decision 2012Da89399 decided December 18, 2013, which determined that wages conditional on continued employment or number of working days should not be classified as ordinary wages due to the lack of fixedness, were overruled.

There is no legal basis for the concept of “fixedness” as presented in the previous precedents. The concept of “fixedness” allowed the parties to attach conditions such as continued employment to wages and, thereby, exclude those

wages from the scope of ordinary wages, which narrowed the scope of ordinary wages without legal grounds and undermined the mandatory nature of ordinary wages. As a result, just compensation as prescribed by law was not provided for the extended, night, and holiday work, and thus, the concept of “fixedness” became inconsistent with the purpose of the Labor Standards Act, which aims to discourage such extended work, etc. In response, the Supreme Court reinterpreted the relevant statutes in a manner that aligns with the function and essence of ordinary wages as a standard wage and, thereby, abolished the concept of “fixedness” and redefined the concept and criteria of ordinary wages, focusing on the compensatory nature of contractual working hours, the essence of ordinary wages. The Supreme Court set forth a new legal doctrine that if an employee fully performs the prescribed work, wages that are determined to be paid regularly and uniformly in return therefor correspond to ordinary wages, regardless of whether any condition related to such wages exists or whether those conditions can be fulfilled. According to the new legal doctrine, if an employee fully performs the prescribed work, on the sole basis of the circumstance that wages are subject to conditions, such as continued employment or days worked within the contractual working days, that should be met, the classification of the employee’s wages as ordinary wages is not negated. This new legal doctrine holds significance in that it meets both the demand to fully reflect the value of prescribed work, essential to determining ordinary wages, and the requirement for prior calculability as a standard wage (predictability in determining ordinary wages) and provides guidelines coherently applicable to various types of wages, including wages conditional on continued employment or days worked.

Meanwhile, for the sake of legal stability and the protection of legitimate expectations, the Supreme Court viewed that the newly established legal doctrine should apply prospectively only to ordinary wages calculated after the date of the relevant judgment; however, the new legal doctrine should be

retroactively applicable to the pending case and other parallel cases (limited prospective effect). This can be considered a measure to uphold the purpose of the change in the previous precedents with a future-oriented approach while simultaneously remedying the rights of the relevant parties, in consideration of the massive ripple effect of a change in the above previous precedents and the need to protect reliance on the previous legal doctrine.

Keywords: ordinary wages, conceptual criteria of ordinary wages, wages conditional on continued employment, wages conditional on days worked, fixedness, Article 6(1) of the Enforcement Decree of the Labor Standards Act, retroactive effect of a change in precedent, prospective effect